

REGULAÇÃO EM NÚMEROS¹

Working Paper²

“Mecanismos de Participação das Agências Reguladoras Federais”

Natasha Schmitt Caccia Salinas³

As agências reguladoras federais costumam realizar consultas e audiências públicas antes de tomarem importantes decisões que afetem direitos de agentes regulados e consumidores.

A “consulta pública” é o mecanismo que permite a qualquer pessoa interessada, inclusive estrangeira, a apresentar contribuições por escrito, especialmente por meio da internet, antes que a agência reguladora venha a tomar uma importante decisão. A agência reguladora também pode realizar “audiência pública”, na qual permite aos interessados apresentar oralmente suas contribuições em sessão pública.⁴

A literatura aponta quatro motivos principais que levam as agências reguladoras a realizar consultas e audiências públicas antes de uma tomada de decisão: (i) conferir legitimidade democrática às decisões das agências; (ii) reduzir assimetrias de informação entre agentes políticos e órgãos reguladores; (iii) dar mais transparência às decisões tomadas pelas agências; (iv) aprimorar a qualidade das decisões tomadas pelos órgãos reguladores.

¹ O “Regulação em Números” é um projeto institucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelos professores Sergio Guerra, Antônio Maristrello Porto e Patrícia Sampaio, e que tem por objetivo desenvolver estudos empíricos sobre agências reguladoras federais. Desenvolvido no âmbito do Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) da FGV Direito Rio, o Regulação em Números atualmente desenvolve três frentes de pesquisa principais: a primeira sobre Mecanismos de Participação (audiências e consultas públicas) das agências reguladoras federais (objeto do presente *working paper*); a segunda sobre Produção Legislativa do Congresso Nacional sobre agências reguladoras; e a terceira sobre controle judicial e externo das agências reguladoras.

² Trabalho em fase de desenvolvimento. Parte dos dados divulgados neste relatório poderão ser alterados, na medida que a alimentação do banco de dados construído pelo Regulação em Números ainda não foi concluída.

³ Professora do programa de Mestrado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio e pesquisadora do projeto Regulação em Números.

⁴ Essas nomenclaturas, no entanto, podem variar. A Agência Nacional de Águas (ANA), por exemplo, adota apenas a expressão “audiência pública” para mecanismos tanto presenciais quanto não presenciais.

As agências reguladoras não estão obrigadas a acatar as sugestões que recebem nas consultas e audiências públicas. No entanto, é dever das agências manifestarem-se sobre as contribuições recebidas, justificando porque pretendem acatá-las ou não.

No Brasil, as agências reguladoras possuem autonomia para estabelecer as regras de suas audiências e consultas públicas. Cada agência faz a gestão de seus mecanismos de participação de modo distinto, seguindo regras e processos diferenciados. Isso gera assimetrias entre elas, que começam pela definição de quando devem ser realizadas as consultas e as audiências públicas.

Esse arranjo difere do adotado nos Estados Unidos, país cujo modelo de Estado Regulador serviu de inspiração ao Brasil. Nos Estados Unidos, as consultas e as audiências públicas de todas as agências são regidas pelas mesmas regras – aquelas contidas na Lei de Processo Administrativo americana (*Administrative Procedure Act*) e geridas por um único sistema eletrônico, o portal *regulations.gov*.

Para quatro das onze agências reguladoras federais atualmente existentes – Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional do Cinema (ANCINE) – a realização de audiências e consultas públicas é facultativa. Para outras quatro – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – as consultas públicas são obrigatórias para a edição de atos normativos que afetam diretos dos agentes regulados e dos usuários. Para a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a realização de consulta pública é obrigatória para a edição de todo e qualquer ato normativo, ao passo que para a Agência Nacional de Mineração (ANM) – última agência reguladora criada – as consultas públicas são obrigatórias quando os atos normativos afetarem, de forma substancial e direta, direitos de agentes econômicos do setor de mineração. Para todas as agências, a realização de audiências públicas é facultativa.

Agência	Mecanismos adotados	Obrigatoriedade	Previsão Normativa
ANA	Audiência Pública	Facultativa	RN n. 52/2011
ANAC	Audiência Pública	Facultativa	

	Consulta Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem direitos dos agentes regulados e dos usuários	Lei n. 11.182/2005 (art. 27) R n. 381/2016
ANATEL	Audiência Pública	Facultativa	Lei n. 9.472/97 (art. 42)
	Consulta Pública	Obrigatória para atos normativos	R n. 612/2013
ANCINE	Audiência Pública	Facultativa	RDC n. 40/2011 RDC n. 56/2013 RDC n. 81/2018
	Consulta Pública	Facultativa	
ANEEL	Audiência Pública	Facultativa	Lei n. 9.427/1996 (Art. 4, § 3º)
	Consulta Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores	RN n. 273/2007 RN n. 483/2012
ANS	Audiência Pública	Facultativa	RN n. 242/2010
	Consulta Pública	Facultativa	
ANTAQ	Audiência Pública	Facultativa	Lei n. 10.233/01 (Art. 68)
	Consulta Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem direitos dos agentes regulados e dos usuários	R 3.585/2012 R n. 2448/2012
ANTT	Audiência Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem direitos dos agentes regulados e dos usuários	Lei n. 10.233/01 (Art. 68)
	Consulta Pública		RN 3.585/2012 RN n. 2448
ANVISA	Audiência Pública	Facultativa	Decreto n. 3.029/1999
	Consulta Pública	Facultativa	
ANP			

	Audiência Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem direitos dos agentes regulados e dos usuários	Lei n. 9.478/97 (art. 19)
	Consulta Pública		Portaria n. 69/2011
ANM	Audiência Pública	Facultativa	Lei n. 13.575/2017 (art. 12)
	Consulta Pública	Obrigatória para atos normativos que afetem, de forma substancial e direta, direitos de agentes econômicos do setor de mineração	
BACEN ⁵	Consulta Pública	Facultativa	Decreto n. 8.243/2014

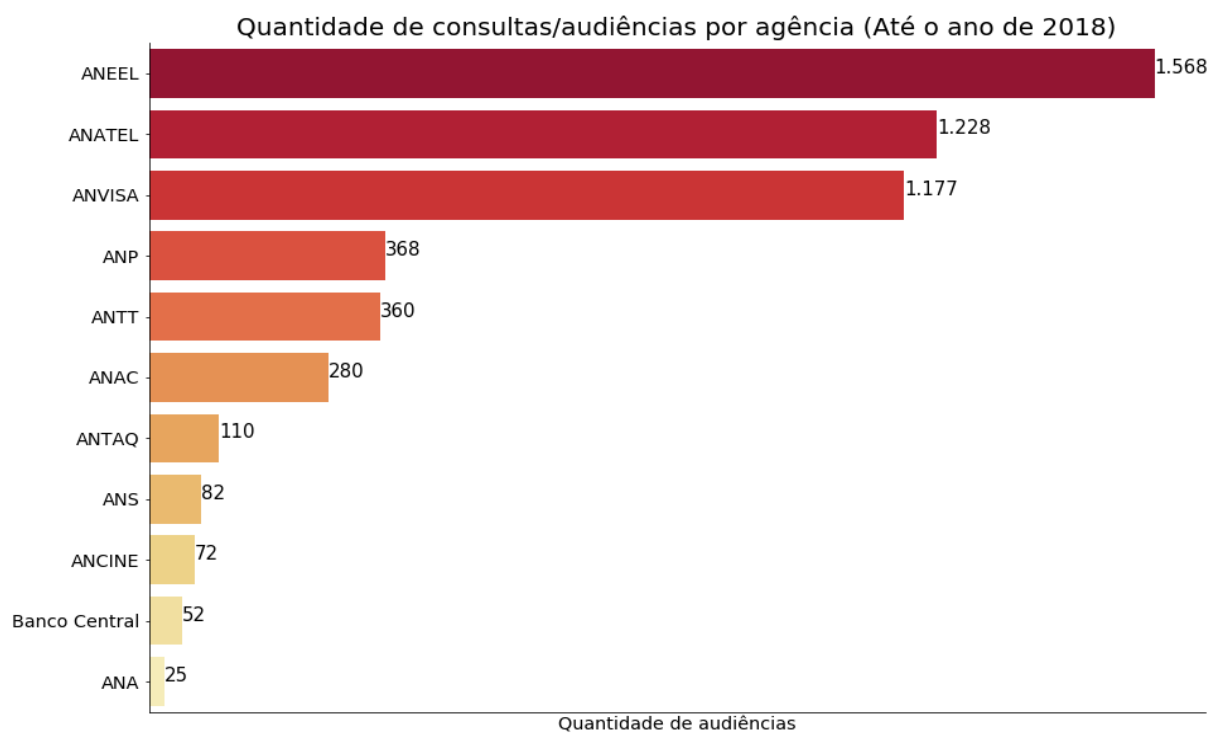
Fonte: Elaboração própria

O número de mecanismos de participação adotados pelas agências reguladoras varia.⁶ A ANEEL, agência reguladora mais antiga, é também aquela que realizou o maior número de consultas públicas. Essa agência submete à consulta pública não apenas propostas de normas, mas também editais de licitação.

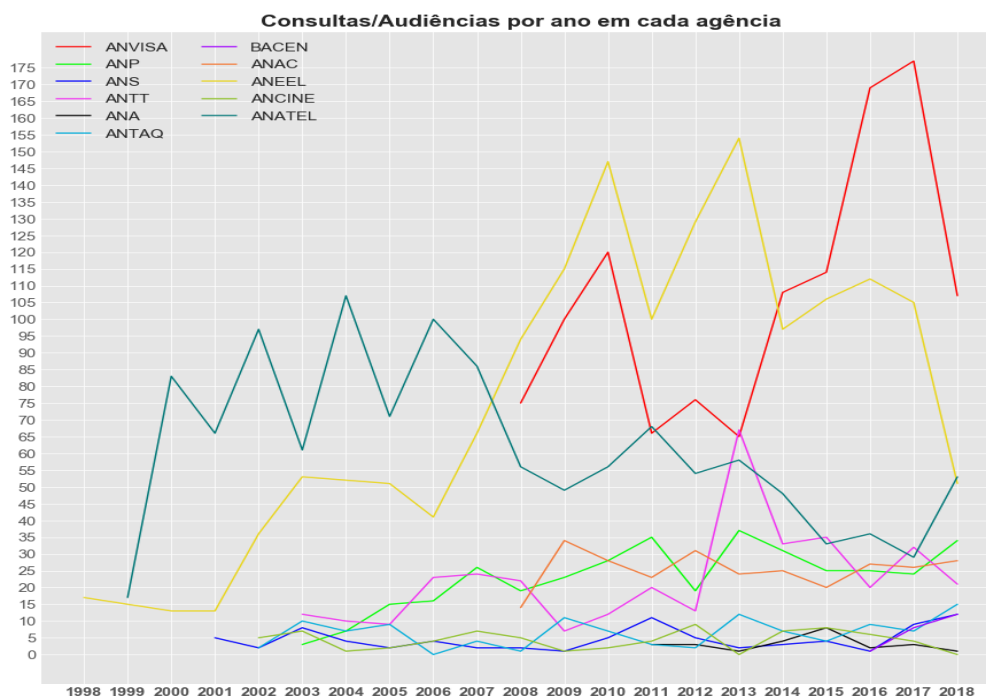
A ANVISA é a terceira agência que mais realiza consultas públicas. Apesar de facultativa para essa agência, a consulta pública é um recurso muito utilizado desde 2008. Somente no ano de 2017, foram 176 consultas públicas realizadas pela agência.

⁵ Em que pese guardar diferenças cruciais em relação às demais agências reguladoras, o BACEN foi incorporado nesta pesquisa por também exercer função reguladora e por utilizar sistematicamente consultas públicas para instruir seu processo normativo.

⁶ Os dados apresentados neste *Working Paper* compreendem o período de início da adoção de consultas e audiências públicas, que varia para cada agência, até dezembro de 2018.



Fonte: Regulação em Números



Fonte: Regulação em Números

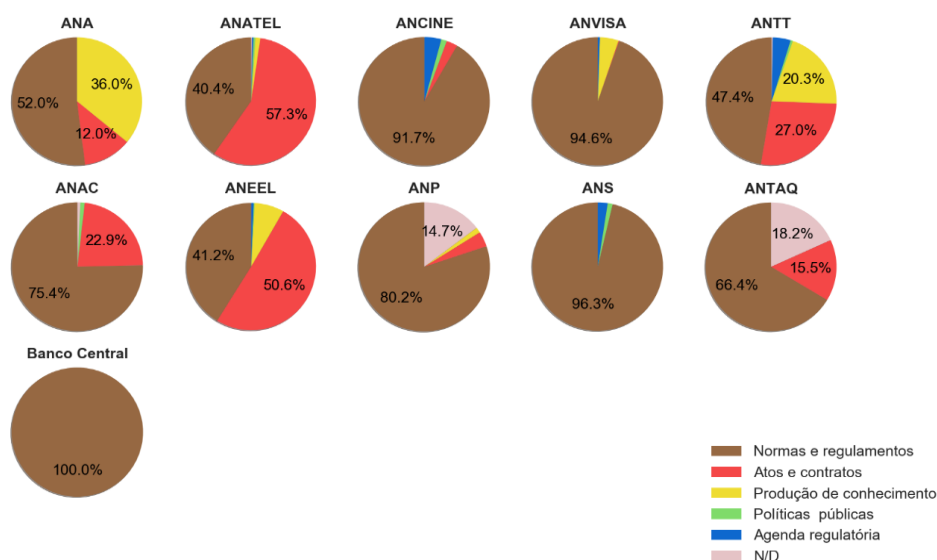
A legislação indicada na tabela acima obriga parte das agências reguladoras acima citadas a realizar consultas públicas previamente à edição de atos normativos, especialmente quando afetarem direitos e obrigações de entes regulados. Nesses casos, as agências submetem à consulta pública uma minuta da norma que pretendem editar, para que qualquer pessoa possa sugerir alterações do texto produzido ou até mesmo reivindicar a não edição da pretendida norma.

As agências reguladoras também adotam mecanismos de participação para outros processos de tomada de decisão. As agências que atuam como poder concedente – caso da ANEEL, ANATEL, ANP, ANTAQ, ANTT, ANAC, ANA e ANP – também estão obrigadas, pelo art. 39 da Lei n. 8.666/93, a realizar audiência pública prévia à publicação de editais de licitação para seleção das concessionárias de serviço público ou de atividade econômica monopolizada pelo Estado.⁷

Algumas agências eventualmente adotam, sem que nenhuma lei as obrigue, mecanismos de participação para a produção de conhecimento preliminar sobre determinado tema regulatório. A ANTT, por exemplo, realiza consultas públicas para receber sugestões sobre estudos de viabilidade técnica e econômica da exploração de rodovias. A ANEEL, por sua vez, realiza audiências públicas para colher informações de usuários de serviços sobre a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado por empresas específicas. Já a ANA realiza audiências públicas não presenciais (via internet) para colher sugestões para aprimoramento de manuais operacionais de barragens hidrelétricas. Quatro agências – ANVISA, ANS, ANCINE e ANTT – têm voluntariamente submetido à consulta pública prévia suas agendas regulatórias. A agenda regulatória é uma peça de planejamento da agência reguladora para o ano ou biênio vindouro. Nela estão contidas as ações regulatórias, fiscalizatórias e sancionadoras prioritárias da agência. Ao submetê-la à consulta ou audiência pública, a agência reguladora possibilita à população participação também em suas decisões estratégicas.

⁷ A audiência pública é exigida para as licitações com valor superior a 100 (cem) vezes o limite mínimo exigido para a licitação na modalidade concorrência. As agências reguladoras, no entanto, submetem à consulta pública editais de licitação com valores inclusive menores do que os exigidos por lei.

Porcentagem de objetivos participação (Por agência)



Fonte: Regulação em Números

O número de participantes nas consultas públicas que tratam da edição de atos normativos varia conforme a agência.⁸ As consultas e audiências públicas que mobilizam centenas ou milhares de participantes são a exceção, e não a regra.

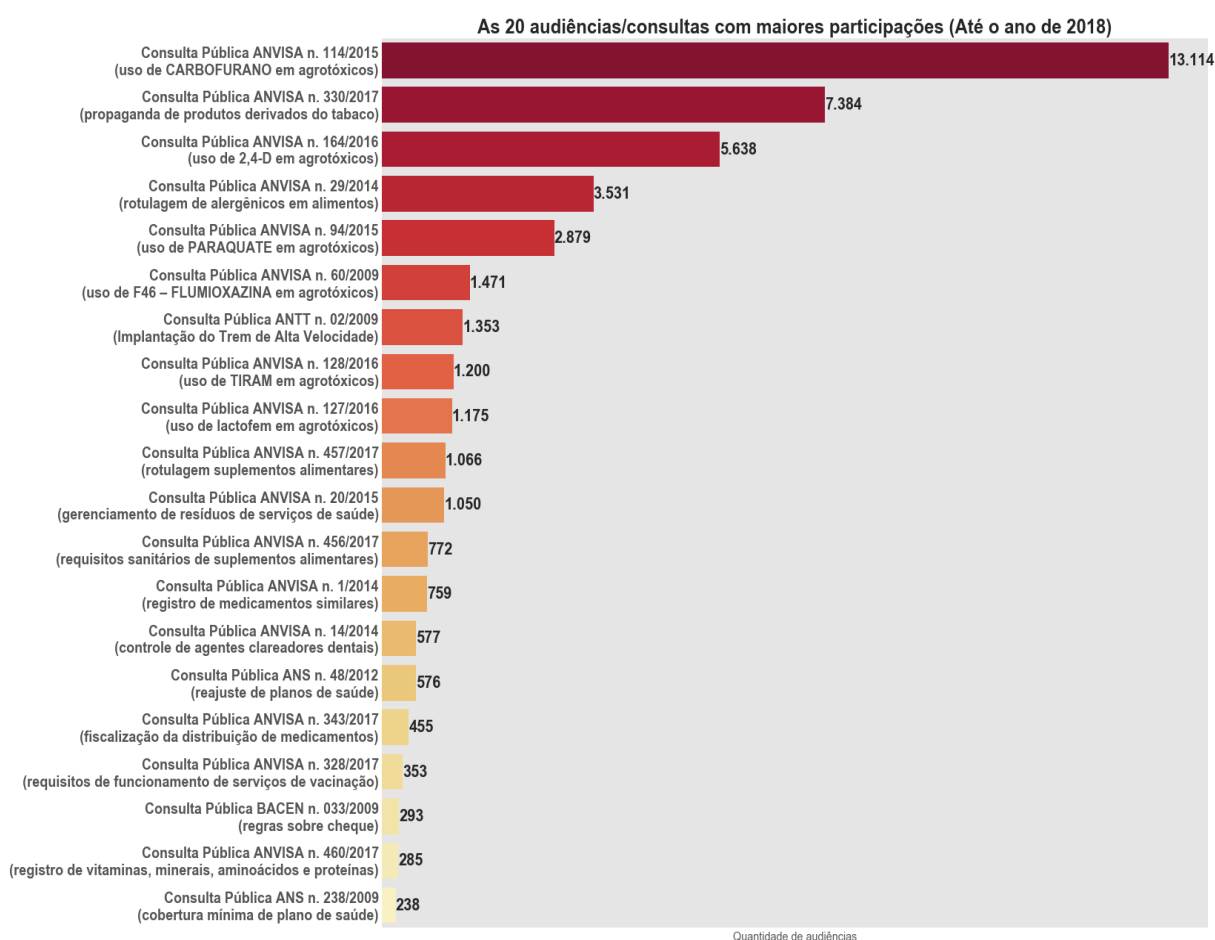
Alguns fatores podem explicar essa baixa adesão, como baixo tempo de preparação para a consulta pública, ou falta de prática da população brasileira em processos decisórios

Um fato interessante é que as consultas e as audiências públicas que mobilizam um grande número de participantes tratam de temas que, não obstante sua complexidade técnica, impactam diretamente a vida de indivíduos, que participam na condição de pessoas físicas.

Na ANVISA, a maioria das consultas públicas que atraem milhares de participantes dizem respeito a normas que permitem ou proíbem o uso de princípios ativos em agrotóxicos. A Consulta Pública da ANVISA n. 114/2015, por exemplo, foi a que mais mobilizou participantes: foram 13.114 participantes, dos quais 99,5% eram pessoas físicas. Nesse caso, a ANVISA pretendia proibir o ingrediente ativo Carbofurano em produtos agrotóxicos no país. Estima-se que pelo menos 65% das contribuições recebidas, provenientes de profissionais agrícolas e do ramo de agronegócio,

⁸ Os dados referentes à mediana da quantidade de participantes são amostrais. Os dados amostrais das agências ANATEL, ANTT e ANAC ainda estão sendo coletados.

manifestaram-se contrariamente à proibição.⁹ A agência, no entanto, decidiu por manter sua decisão inicial. Na Consulta Pública n. 164/2016, terceira com maior participação, fenômeno inverso ocorreu: a ANVISA pretendia manter o uso do ingrediente ativo 2,4-D em agrotóxicos, sendo que milhares de trabalhadores rurais se mobilizaram para manifestar sua discordância na consulta pública¹⁰. A decisão final da ANVISA sobre o uso deste ingrediente ativo ainda não foi tomada.



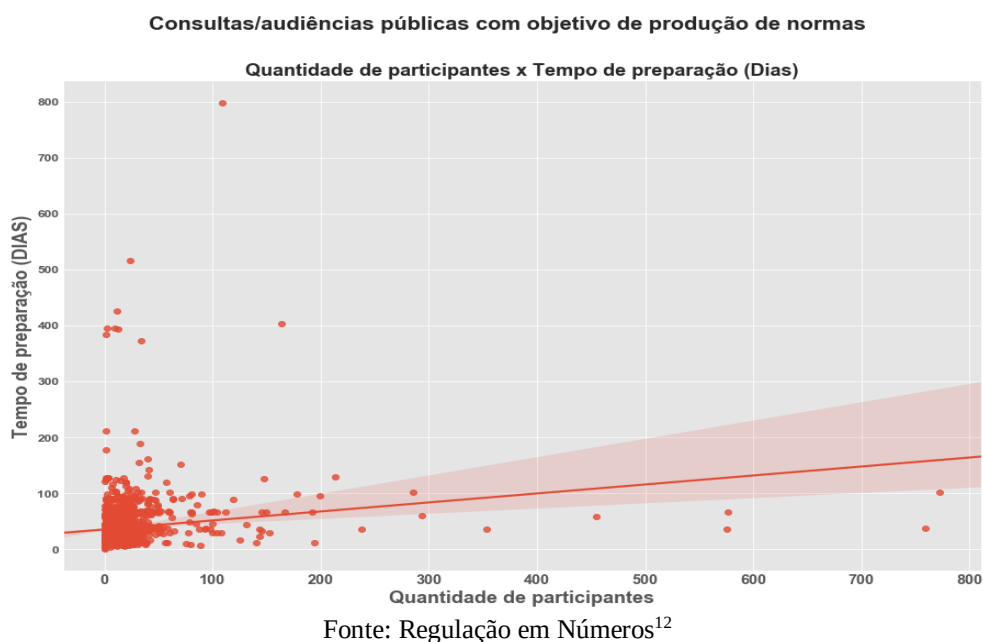
Fonte: Regulação em Números

Um achado importante da pesquisa em desenvolvimento do projeto Regulação em Números é o de que o tempo de preparação oferecido pela agência aos contribuintes influencia o número de

⁹ Para obter este dado, selecionamos os contribuintes que discordaram da proposta da ANVISA a partir de palavras-chave representativas dessa discordância. É possível, no entanto, que haja mais pessoas com mesmo posicionamento.

¹⁰ Segundo Relatório de Participação Social n. 19/2016 da ANVISA, 4.809 participantes (equivalente a 85,2% do total) discordaram da proposta de resolução da agência.

participantes nas consultas públicas. O tempo de preparação corresponde ao intervalo de tempo entre a data de aviso da consulta pública pela agência reguladora e o prazo limite para recebimento das contribuições por escrito. As audiências com menor número de participantes são também aquelas em que o tempo de preparação também é menor.¹¹



Esse dado revela a necessidade de se fazer um diagnóstico mais abrangente dos mecanismos de participação promovidos pelas agências reguladoras para que estratégias de engajamento da população nas consultas e audiências públicas tornem-se mais eficazes.

¹¹ É importante ressaltar que, para esta análise, os *outliers* (valores atípicos que se afastam muito da média) foram excluídos do gráfico com o intuito de que os mesmos não afetassem a média e a visualização do gráfico. Para isso, foi usada a seguinte fórmula: média + (2 x desvio padrão).

¹² Este gráfico não inclui dados das consultas e audiências públicas realizadas pela ANAC, ANATEL e ANTT. É importante ressaltar que, para esta análise, os *outliers* (valores atípicos que se afastam muito da média) da quantidade de participantes foram excluídos do gráfico para não enviesar a análise. Para o cálculo do *outlier*, foi usada a seguinte fórmula: média + (2 x desvio padrão). Além disso, o gráfico inclui apenas dados disponíveis de 37% de todas as consultas ou audiências públicas. Os dados remanescentes ainda não foram coletados ou não foram disponibilizados pelas agências.